

1500079-82.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... que o réu estava em ponto de tráfico na companhia do adolescente e que ambos confessaram a prática do tráfico e cada um indicou onde estavam escondidas mais drogas. Aliás, importante anotar que, conforme foto de fls. 14, os entorpecentes estavam embalados de forma idêntica. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na inicial. A causa de aumento restou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500079-82.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000041

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2008650/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22370991 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

107/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2008650 - 02º D.P. PIRACICABA, 107/22/922

- 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO FELIPE DOS SANTOS

Réu Preso

Aos 07 de junho de 2022, às 13:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. ANTONIO CARLOS PEREZ ANTUNES DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: DIEGO FELIPE DOS SANTOS - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC PAULO FRANCO JÚNIOR - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha GC JOEL VASCONCELOS DE LIMA.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que desistia da oitiva

da testemunha GC PAULO FRANCO JÚNIOR, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha GC PAULO FRANCO JÚNIOR, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu DIEGO FELIPE DOS SANTOS foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "DIEGO FELIPE DOS SANTOS, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06., pois no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 19h35min, na Rua Iuguslavia, nº 01, Bairro Água Branca, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, previamente ajustado e com identidade de propósitos com o adolescente Heitor Barrichello Vitti, para fins de tráfico, trazia consigo e tinha em depósito, 14,8g de cocaína, distribuídos em 44 papelotes, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 81/84) O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 12/13, foto a fl. 14 e laudo pericial a fls. 90/93. Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva. De fato, o guarda relatou, na fase informativa (fls. 02), que "Estava em patrulhamento de rotina pela Rua Iguslândia. O guarda afirma que, em determinado momento, avistou dois indivíduos gesticulando havia, como se quisesse chamar a atenção de condutores de veículos que passavam pelo local. O guarda afirma que os indivíduos não perceberam a aproximação da viatura, sendo abordados no local rapidamente. O guarda afirma que, em revista pessoal, localizou quatro porções de cocaína na boca do menor infrator HEITOR e duas porções de cocaína na boca do implicado DIEGO. O guarda afirma que HEITOR informou que havia mais entorpecente no final da via. Segundo o guarda, no local indicado por HEITOR, localizou trinta e três porções de cocaína. O guarda afirma que ainda indicado pelos autores, encontrou três porções de cocaína ao lado de um poste na Rua Miguel Caparros, altura do número 495, e mais duas porções de cocaína do outro lado da via. O guarda afirma que, de maneira informal, os indivíduos confirmaram que estavam realizando traficância de drogas no momento da abordagem". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que provavelmente não foi apreendida quantia em dinheiro porque já havia sido feita a denominada "sangria" pelo gerente do local que passa recolhendo o dinheiro. Disse também que o réu e o menor disseram que estavam atuando juntos no tráfico. Assim, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. De fato, o acusado admitiu que estava no local como olheiro dos traficantes e que possuía 2 papelotes na boca. Ademais, os GCM informaram que o réu estava em ponto de tráfico na companhia do adolescente e que ambos confessaram a prática do tráfico e cada um indicou onde estavam escondidas mais drogas. Aliás, importante anotar que, conforme foto de fls. 14, os entorpecentes estavam embalados de forma idêntica. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na inicial. A causa de aumento restou demonstrada, visto que pelo depoimento do GCM ficou claro que o réu estava atuando no tráfico juntamente com o adolescente e até admitiu informalmente isso. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu ostenta maus antecedentes criminais, conforme fls. 132/133 e está sendo processado por outro delito de tráfico de entorpecentes (certidão a fls. 86/87). Como se já não bastasse, em virtude da quantidade e nocividade de drogas apreendida, restou claro

que se dedica a atividades criminosas e não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e, conseqüentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Guardas Municipais são ilícitas, eis que a abordagem e a prisão do acusado decorreram de autoridades incompetentes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, § 8º, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo o referido dispositivo reproduzido de forma idêntica na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, de acordo com as referidas disposições, vislumbra-se que a atual ordem jurídica contempla quais são as específicas atribuições da Guarda Municipal, órgão ao qual incumbe a defesa e proteção dos bens, serviços e instalações em âmbito municipal. Ou seja, as Guardas Municipais não têm status de polícia ostensiva, função esta que cabe a Polícia Militar do Estado de São Paulo. No caso em tela, verifica-se que houve flagrante invasão de competência material, pois a Guarda Municipal atuou como se fosse polícia ostensiva. Nesse aspecto, cumpre mencionar que os Guardas, de forma ilegal, abordaram o acusado sem que qualquer situação de flagrante delito estivesse visível, ainda que fossem autoridades incompetentes para tanto. Essa função, todavia, não incumbe aos Guardas Municipais, mas à Polícia Militar. Na realidade, os Guardas Municipais, diante do fato, deveriam ter acionado o órgão competente para atender à ocorrência. Na atual ordem jurídica, existe a polícia ostensiva, representada pela Militar, e a polícia judiciária, representada pela Civil. Assim, os Guardas jamais poderiam ter atuado como se possuíssem aptidão para tanto. Há, no caso em comento, evidente invasão de competência administrativa, de índole constitucional, o que enseja a ilegalidade do ato (prisão em flagrante) e de todas as provas carreadas aos autos, visto que elas são provenientes, todas, de atos dos aludidos Guardas Municipais que atuaram como polícia ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação Penal - Desarmamento - Guarda Municipal - Ação de polícia ostensiva - Ilegalidade - Apelo provido para absolver o acusado." (TJSP, ACri nº 990.09.226504-0 - 2ª câmara de direito criminal - origem: Piracicaba/SP, julg. 1º/02/10); "Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes - Prisão dos réus efetuada por Guardas Municipais - Afirmação dos servidores da realização de campana para confirmar o crime - ilegalidade da ação reconhecida - Admissão, no caso presente, da existência de prova que contamina a ação penal Apelo provido para absolver os réus." (TJSP, ACri nº 0032340-54.2011.8.26.0602 - 2ª Câmara de Direito Criminal - origem: Sorocaba/SP, julg. 12/11/2012). Inclusive, nas palavras do Ilustre Desembargador relator da Apelação Criminal nº 0032340-54.2011.8.26.0602, cuja ementa se encontra acima transcrita e que teve origem na Comarca de Sorocaba/SP, onde também é usual que a Guarda Municipal exerça as tarefas da polícia ostensiva, defendeu, com grande propriedade, o Dr. Almeida Sampaio: "Fica delineado, de maneira bastante evidente, portanto, que, dentro da divisão das atribuições das Polícias, somente à Militar é outorgado constitucionalmente o poder de exercer o policiamento ostensivo, cabendo tão-somente à Guarda Municipal a proteção de seus bens, serviços e instalações". E

ainda: “Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para prender eventual traficante.”. Por fim, é cediço que qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em flagrante – embora essa situação não tenha restado demonstrada nos autos, eis que o acusado não foi visto praticando atos que indicassem o comércio de entorpecentes - e, por isso, em tese, a Guarda Municipal também teria esse poder. Contudo, o que não é permitido é que uma Instituição que tem por função a proteção do patrimônio público se utilize de um poder que não possui e atenda ocorrências, realize investigações e efetue abordagens, a fim de efetuar uma prisão em flagrante. Entretanto, caso não sejam acolhidos os argumentos formulados, ainda em sede PRELIMINAR, verifica-se que as provas também são ilícitas porque foram constituídas a partir de uma busca pessoal irregular. Com efeito, em relação à busca pessoal, é de se observar que ela não observou os requisitos previstos no artigo 240 do Código de Processo Penal. Isso porque os Policiais declararam que fizeram a abordagem do réu porque ele apresentou “atitude suspeita”, sem fossem visualizadas condutas prévias que indicassem o seu envolvimento no comércio de entorpecentes ou que existissem denúncias prévias a respeito do acusado. Ora, evidente, portanto, que não havia qualquer suspeita da prática to tráfico de drogas a ensejar a busca pessoal, revestindo-a, portanto, de ilegalidade. Nesse sentido, observe-se o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, determinando-se o trancamento da ação penal. 3. Recurso em habeas corpus provido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal. (RHC 142.588/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021). Todavia, caso sejam rejeitadas todas as preliminares suscitadas pela Defensoria Pública, QUANTO AO MÉRITO, verifica-se que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Joel, GCM, declarou que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram dois indivíduos. Efetuaram a abordagem de ambos e, em revista pessoal, encontraram entorpecentes na boca dos dois. Eles confessaram informalmente que estavam traficando e indicaram o local onde estava o restante das drogas. Já tinha abordado o adolescente em outras ocasiões. O local é ponto de venda de cocaína. O entorpecente que estava escondido estava embalado da mesma forma e era da mesma natureza do que foi encontrado com o réu e o adolescente. Ambos estavam sozinhos. O local onde as drogas estavam era próximo ao local onde os dois foram vistos. Cada um dos réus estava com o um “kit” e escondeu em um local diferente. Os dois estavam juntos. Antes da abordagem, conseguiram visualizar que o réu e o adolescente gesticulavam para os veículos que passavam, como se quisessem chamar a atenção de quem quisesse comprar drogas. Ambos confessaram que estavam traficando juntos. Não se lembra se eles falaram alguma coisa a respeito de não ter sido encontrado dinheiro, acredita que alguém já devia ter recolhido. Cada um indicou um local onde estava escondendo o entorpecente. O réu, em interrogatório, declarou que estava trabalhando no local como “olheiro”, pois tinha contraído dívidas com os traficantes em virtude de sua outra prisão. Estava com duas porções de cocaína na

boca, para seu consumo pessoal. O traficante era o adolescente Heitor. Falou para os Guardas quem era o gerente do ponto de tráfico. Está arrependido. Por conta da prisão anterior, começou a receber mensagens pelo Facebook e foram até a sua casa um dia e disseram que ele iria ter que voltar a vender drogas. Inicialmente, negou, então eles ofereceram a função de "olheiro". Ficava sentado em uma praça onde tinha visão das duas avenidas. Estava próximo ao adolescente quando os Guardas chegaram porque tinha acabado de pegar as drogas para seu consumo e estava voltando para o local onde ficava. Foi o adolescente quem indicou o local onde as drogas estavam. Fazia 04 dias que trabalhava como "olheiro". Foi ameaçado em virtude da segunda prisão. Na segunda prisão, estava apenas indo comprar drogas para seu consumo. Excelência, o acusado, como visto, nega a prática do tráfico de drogas. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque as provas reunidas pela acusação se resumem às palavras dos Guardas responsáveis pela prisão do réu. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande

maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos Policiais como fundamento para uma condenação, verbis: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-

57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais, nenhum ato efetivo de comércio foi avistado antes da abordagem, além de não terem sido apresentados outros indivíduos como eventuais compradores das substâncias entorpecentes e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Ademais, grande parte dos entorpecentes não estava sob a posse direta do acusado, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. E a suposta confissão informal do acusado não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Dessa forma, ante a manifesta insuficiência probatória, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Não sendo acolhida a tese absolutória, postula-se, então, a DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 37 DA LEI Nº 11.343/06. Excelência, pelo que se observa do depoimento do réu, ele mesmo informa que exercia a função de "olheiro" no local, ou seja, colaborava informalmente para outro indivíduo que exercia o tráfico de drogas. As demais provas produzidas nos

autos não desqualificam as suas alegações, até mesmo pela dinâmica dos fatos visualizada pelos Policiais. Logo, a desclassificação da conduta é medida de rigor, nos termos legais. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado, à época dos fatos, era tecnicamente primário. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu. Além disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: “Artigo 2º – Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) “Grupo criminoso organizado” - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; (...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a “integrar organização criminosa”, é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida)” (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Postula-se, ainda, o AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. Com efeito, Excelência, o fundamento dessa previsão diz respeito à proteção da integridade da criança e do adolescente enquanto pessoa em desenvolvimento, de modo que, para tanto, devem existir provas de que o adolescente não possuía envolvimento anterior na prática do tráfico de drogas ou em outros atos infracionais, o que não pode, por si só, ser presumido. Além disso, não basta a prática do delito em coautoria, há a necessidade de que se demonstre, no curso da instrução, a influência negativa do acusado sobre o adolescente, o que não ocorreu no presente caso. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu, tecnicamente primário; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal); (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como

sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, com as substituições de pena que se mostrarem cabíveis, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:
"Vistos.

DIEGO FELIPE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 19h35min, na Rua Iugoslávia, nº 01, Bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com identidade de propósitos com o adolescente H.B.V., trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 14,8g de cocaína, distribuídos em 44 papелotes, substância entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado e o menor ajustaram-se para vender drogas no local dos fatos naquele dia e para lá dirigiram-se. Guardas civis municipais estavam em patrulhamento de rotina pela rua acima quando avistaram dois indivíduos que estavam em atitude suspeita pela via e resolveram abordá-los. Em revista pessoal, localizaram quatro porções de cocaína na boca do menor infrator e duas porções de cocaína na boca do acusado. Na sequência, o adolescente indicou que havia mais drogas no final da rua. No local indicado por H., havia mais 33 porções de cocaína, embaladas da mesma maneira que as que estavam na boca deles. Eles informaram, ainda, que havia mais droga na Rua Miguel Caparrós, sendo localizadas mais três porções de cocaína ao lado de um poste e outras duas porções de cocaína do outro lado da referida via. O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 103) e apresentou defesa preliminar (fls. 107/111), seguindo-se a decisão de fls. 112/114, que recebeu a denúncia.

Designada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. Após, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. O E. Supremo Tribunal Federal, a fim de coibir excessos e arbitrariedade, assentou entendimento segundo o qual o ingresso em residência, sem autorização do morador e sem ordem judicial, para ser lícito, demanda quadro de fundada suspeita de situação de flagrante delito. Logo, os policiais somente podem adentrar em residência se tiverem dados concretos indicativos da ocorrência de um crime, impondo-se controle jurisdicional posterior da diligência para se definir se a ação policial era justificada ou não.

Confira-se, sobre o tema, o julgado em que assentado o entendimento do Pretório Excelso: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da

Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (STF, RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes).

Esse mesmo entendimento pode ser aplicado à busca pessoal, face ao que dispõe o art. 240, § 2º, do CPP.

No caso em tela, os guardas atestaram que avistaram o réu e outro indivíduo, em local conhecido como de intenso tráfico de drogas, gesticulando para veículos que por ali passavam.

A abordagem do acusado, portanto, não constituiu ação arbitrária. Havia justa causa para a ação, sendo lícitas as provas daí decorrentes.

2. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, pela fotografia de fls. 14 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 90/93, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu valeu-se do direito de permanecer em silêncio (fls. 05).

Em juízo, confessou a prática do crime. Disse que foi preso anteriormente por tráfico e saiu no dia 09 de dezembro. Asseverou que passou o fim do ano com a família, mas, quando começou o ano, foram atrás dele para que vendesse droga para pagar a dívida anterior. Porém, falou que não ficaria com a droga, porque já tinha sido preso, de modo que acabou ficando como olheiro. Alegou que ficava sentado num banco, numa praça, de onde tinha visão das duas avenidas, e o menor ficava na rua, vendendo. No dia dos fatos, tinha acabado de se aproximar do menor, pegou dois papелotes de cocaína, que eram para seu uso, e voltava para seu ponto quando foram abordados. Asseverou que o menor indicou onde estava a droga. Disse que estava havia quatro dias naquela função. Aduziu que se arrependia do que tinha feito e deveria ter procurado a polícia para falar sobre as ameaças que ele, a mãe e o irmão menor sofreram.

O guarda municipal Joel narrou que estavam em patrulhamento em local já conhecido por intenso tráfico de entorpecentes quando visualizaram dois indivíduos e fizeram a abordagem. Em revista pessoal, encontram entorpecente na boca dos dois, um menor e outro maior. Atestou que eles confessaram que estavam traficando e indicaram onde estava escondido o restante da droga, perto de onde eles estavam. Aduziu que, antes de notar a presença da equipe, os agentes estavam gestos para os condutores dos veículos, possivelmente para indicar que estariam na venda de drogas.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Paulo, ouvido a fls. 03.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas

municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E “como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas municipais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado: “Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Alegação de ilegalidade da prisão realizada por Guardas Municipais. Atuação dos Guardas Municipais. Ausente ilegalidade – Artigo 301 do CPP – Qualquer pessoa do povo pode, e as Autoridades policiais e seus agentes devem realizar prisões em flagrante – Crime de Tráfico de Drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Jurisprudência do C. STJ. No caso em tela, ao que consta, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. No mais, eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva do Paciente.

Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2014342-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

Não bastasse essa orientação já consolidada na jurisprudência, há que se ressaltar que, conquanto não seja essa essencialmente sua função, o guarda municipal está autorizado por norma legal expressa a encaminhar à presença da autoridade policial indivíduos presos em flagrante delito, consoante a regra inscrita no artigo 5º, inciso XIV, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

Enfim, o fato de os guardas municipais terem flagrado o acusado e o adolescente juntos no local, vindo a localizar duas porções de cocaína na boca de DIEGO e duas porções de cocaína na boca do adolescente, bem como 40 porções da mesma droga, embaladas de maneira idêntica às encontradas em poder deles, nos locais por eles indicados, aliados à confissão do réu de que atuava no tráfico, ainda que como olheiro, conduzem à certeza quanto a autoria e à traficância.

Consigno que não inocenta o réu a alegação de que teria sido ameaçado em razão de dívida de drogas e, por isso, estava traficando. A uma porque não foi amparada por qualquer elemento de prova. A duas porque a ausência de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa reclama, para sua configuração, que o sujeito não possa praticar comportamento diverso do que o vedado por lei, o que não acontece quando alguém se diz impelido a traficar porque alguém a determinou que fizesse, pois, ainda que verdadeira a alegação, podia abster-se da prática criminosa.

Sobre o tema o seguinte julgado: Apelação Criminal nº 1525099-29.2019.8.26.0228, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 15.04.20; Apelação Criminal nº 0002812-52.2018.8.26.0400, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 14.04.20 14, e Apelação Criminal nº 1500428-95.2018.8.26.0544, Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi, j. 12.05.20.

Acrescento, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP - RJTJSP, 101/498). Impõe-se, por conseguinte, a condenação do réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, valendo anotar que, para sua caracterização, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente porte, traga consigo e tenha em depósito substância entorpecente.

Descabe a desclassificação para o crime descrito no artigo 37 da Lei de Tóxico. Ainda que se possa admitir que o réu atuava como “olheiro”, como ele alegou em juízo, tem-se que, nessa função, participava diretamente da própria execução do delito, em divisão de tarefas, figurando, portanto, como coator, o que não se confunde com a conduta prevista no art. 37 da Lei 11.343/06, de mero prestador de “informações”.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci, in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Ed. Forense, 8ª ed., pág. 367: “... o intuito do legislador, ao adotar no tipo penal do artigo 37, da Lei nº 11.343/06, a teoria pluralista do concurso de agentes não foi a de alcançar aqueles que exercem funções habituais no tráfico, como o 'olheiro', pois este é coautor da conduta descrita no artigo 33, mas sim aqueles que normalmente não integram a associação criminosa, em suas diversas funções hierárquicas, mas acabam colaborando com informações privilegiadas e estratégicas para o exercício da traficância”.

Sobre o tema o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça: “Tráfico de entorpecentes. Agente que exercia a função de “olheiro”. Envolvimento não limitado a fornecimento de informação isolada a traficante. Coautoria ativa e intensa no comércio ilícito de entorpecentes. Desclassificação para a conduta prevista no art. 37 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Em se cuidando de agente que exercia a função de “olheiro”, ostentando envolvimento não limitado a mero fornecimento de informação isolada a traficante, mas sim verdadeira coautoria ativa e intensa no comércio ilícito de entorpecentes, não se cogita de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no art. 37 da Lei n. 11.343/06” (Apelação Criminal nº 1500948-14.2020.8.26.0535, Rel. Des. Grassi Neto, j. 29.10.20).

Por fim, ficou devidamente caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, eis que as circunstâncias da ocorrência, descritas pelos guardas, bem como a confissão do conluio, confirmaram o envolvimento do adolescente na prática do crime.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal. Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, anoto que o réu ostenta condenação transitada em julgado pela prática de tráfico (autos 1501259-70.2021, também desta 4ª Vara Criminal- cf. certidão às fls. 86/87 e extrato às fls.

132/133), a qual, embora não induza à reincidência, dada a data do trânsito, caracteriza Maus Antecedentes.

Consigno que, para o reconhecimento dos Maus Antecedentes, não se exige, como para a reincidência, que o trânsito em julgado da condenação anterior seja anterior ao crime tratado, bastando que a condenação decorra de fato ocorrido anteriormente. Não importa que tenha o trânsito em julgado da condenação ocorrido depois dos eventos analisados nos presentes autos, pois o que se exige para a configuração dos Maus Antecedentes é que o fato seja anterior e que a condenação seja definitiva, a fim de se evitar qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência (cf. Apelação nº 0001448-64.2017.8.26.0599, Rel. Des. Newton Neves, j. 22.02.19). No mesmo sentido já decidiu o E. STJ: "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar Maus Antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 31/8/2018). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, em seu valor unitário mínimo. Não há circunstâncias agravantes. De outro lado, o réu confessou a prática do crime, razão pela qual reduzo a pena fixada para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na terceira fase de fixação da pena, aplico o aumento de um sexto, face ao disposto pelo art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, resultando cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. De outro lado, o réu não faz jus à redução prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, eis que ostenta Maus Antecedentes, decorrentes inclusive de condenação pela prática de crime de tráfico. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu DIEGO FELIPE DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena e vedado o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra preso e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.
2) Recebo o recurso interposto.
3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.
4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.
5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.
6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 06/06/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]